

0000122-46.2018.8.26.0660

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

Comarca: Viradouro

Foro: Foro de Viradouro

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na área verde da Prefeitura, às margens do córrego Viradouro, inclusive com congestionamento de carros, à noite, para adquirir a droga, sendo que o chefe do tráfico seria um indivíduo conhecido pelo vulgo de 'Biel', conhecido nos meios policiais desta cidade por envolvimento no tráfico de drogas. 'Biel' teria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Viradouro

Foro de Viradouro

Vara Única

Rua José Borelli, 10, Viradouro - SP - cep 14740-000

0000122-46.2018.8.26.0660 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000122-46.2018.8.26.0660

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO MANINI e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

LEONARDO MANINI, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso na conduta descrita pelo artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal; e HIGOR HENRIQUE DE SOUZA e GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI, também já qualificados, foram denunciados como incursos na conduta descrita pelo artigo 35, caput e artigo 37, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, no dia 19 de setembro de 2017, por volta das 09h30, na Avenida João dos Santos Filho, bairro Jardim Maria Luiza, nesta cidade e comarca, LEONARDO MANINI trazia consigo, para fins de tráfico, 4,95 gramas de cocaína, acondicionados em 04 microtubos plásticos e 04 segmentos plásticos transparentes contendo 18,73 gramas de maconha, tratando-se de substâncias que causam dependência física e química, sendo que o fazia sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda segundo a denúncia, no dia 26 de setembro de 2017, por volta das 14h30, na Avenida João dos Santos Filho, bairro Jardim Progresso, nesta cidade e comarca, HIGOR HENRIQUE DE SOUZA e GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI, colaboravam como informantes para associação destinada à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente.

Por fim, narra a denúncia, que, em data incerta, mas anteriormente ao dia 19 de setembro de 2017, nesta cidade e comarca, LEONARDO MANINI, HIGOR HENRIQUE DE SOUZA e GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI, associaram-se para o fim de praticar crimes de tráfico ilícito de entorpecente, incluindo os abaixo descritos.

Os acusados foram pessoalmente notificados (fl. 202-Higor, 204-Gabriel, 206-Leonardo) e apresentaram defesa prévia (fls. 207/209-Leonardo, 225/232-Higor, 233/237-Gabriel).

A denúncia foi recebida no dia 17 de dezembro de 2020 pela decisão de fls. 242/245 e os réus foram citados (fls. 281-Higor, 283-Leonardo, 287-Gabriel).

Foi designada audiência de instrução e julgamento, que ocorreu de forma virtual, em decorrência da pandemia da Covid-19, oportunidade em que se procedeu à inquirição das testemunhas e, por fim, ao interrogatório dos acusados.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram as alegações finais.

É o relatório. Fundamento e decido.

A Defesa de GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI suscita preliminar de nulidade processual, argumentando que “o denunciado já respondeu por meio de outro processo (Feito nº 0000630- 89.2018.8.26.0660) pelos mesmos fatos narrados na denúncia que está aportada ao Processo em testilha”, pois “o denunciado já foi processado e absolvido pelo Tribunal ad quem da imputação do artigo 35”. Em acréscimo, argumenta que teria o Parquet inovado ao alargar os termos da persecução penal anterior, que nada tratou da suposta prática do delito previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006. Malgrado a questão não se afigure tecnicamente como nulidade processual, ao realizar o devido exame da preliminar de coisa julgada, tenho que a tese defensiva merece acolhimento.

A denúncia oferecida nos autos n. 0000630- 89.2018.8.26.0660 registra:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de junho de 2018, por volta das 13h00min, no interior da residência situada na Rua Sebastião da Penha Belmiro, 50, Centro, bem como nos terrenos defronte e aos fundos do aludido imóvel, nesta cidade e comarca de Viradouro, os denunciados GABRIEL e LEONARDO guardavam e mantinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 28 (vinte e oito) invólucros de papel alumínio acondicionando a substância conhecida como “crack”, com peso bruto de 10,53 g (dez gramas e quinhentas e trinta miligramas), 10 (dez) invólucros plásticos contendo a substância “maconha”, com peso bruto de 33,37 g (trinta e três gramas e trezentas e setenta miligramas), e 26 (vinte e seis) microtubos plásticos do tipo eppendorf acondicionando a substância “cocaína”, com peso bruto de 21,88 g (vinte e uma gramas e oitocentas e oitenta miligramas), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 19/30) e laudos de constatação provisória da natureza das drogas (fls. 35/38 e 39/42).

Outrossim, consta que, em condições de tempo e local ignorados, mas antes do dia 12 de junho de 2018, os denunciados GABRIEL e LEONARDO se associaram para o fim de juntos cometerem o crime de tráfico de drogas.

(...)

Segundo o apurado, informações policiais davam conta de que o denunciado GABRIEL, alcunhado de “BIEL”, seria o responsável pelo tráfico de drogas na região do bairro Jardim Maria Luíza II, nesta cidade. Ante tais fatos, as policiais militar e civil do município passaram a realizar patrulhamento extensivo pela região.

O policial militar Adriano, em uma dessas ocasiões, no ano de 2017, realizou uma incursão em uma área de mata no referido bairro e logrou êxito em apreender drogas na citada mata, de um indivíduo que se evadiu. Outrossim, apreendeu um rádio HT de outro indivíduo e constatou a comunicação entre os envolvidos no tráfico naquela área. Os responsáveis pelo tráfico de drogas utilizavam rádios HT para se

comunicarem e se informarem sobre possíveis movimentações policiais. Nessa ocasião, o policial militar Adriano, reconheceu a voz de "BIEL", o qual estimulava seus subordinados a trocarem tiros com a polícia, bem como dizia que naquele momento estariam fugindo, mas, no futuro, revidariam.

(...)

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI e LEONARDO BRITO GARCIA como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

Após sentença que condenou apenas GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI pela prática do tráfico de drogas, o e. TJSP reformou a decisão, acolhendo a pretensão acusatória quanto aos dois acusados, mas somente em relação ao art. 33 da Lei de Drogas e em sua forma privilegiada.

No presente feito, há nova imputação do delito de associação para o tráfico contra GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI, agora somada à suposta atuação dele como informante.

Sobre o art. 35 da Lei n. 11.343/2006, observo que a denúncia no presente feito noticia que o delito foi praticado "em data incerta, mas anteriormente ao dia 19 de setembro de 2017" e a peça acusatória constante dos autos n. 0000630-89.2018.8.26.0660 trata do mesmo tipo penal, que teria sido praticado "em condições de tempo e local ignorados, antes do dia 12 de junho de 2018".

Assim, tenho que a persecução penal objeto do feito anterior, de maior abrangência temporal, engloba os fatos descritos nesses autos, sendo tal conclusão reforçada pelo teor da denúncia, que cita a apreensão de um rádio HT pelo policial militar Adriano (fls. 138/143 dos autos n. 0000630- 89.2018.8.26.0660), e sentença de mérito, que consignou restar "comprovado que o réu [GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI] se dedicava à atividade criminosa e tinha até rádios HTs" (fls. 326/332 daqueles autos).

Ou seja, o episódio relativo à localização do rádio transmissor pelo militar RONALDO ADRIANO LOPES – principal fato descrito pela acusação neste feito para fundamentar a imputação relativa ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006 – foi objeto de expressa apreciação judicial anterior e seu exame resta obstado pela existência da coisa julgada.

Igual sorte deve ter a pretensão condenatória em desfavor de GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI no que tange ao art. 37 da Lei de Drogas.

Quanto ao tipo penal, cumpre ressaltar que:

"O crime do art. 37 da Lei de Drogas funciona como verdadeiro tipo penal subsidiário (soldado de reserva) em relação à associação para fins de tráfico (art. 35). Em outras palavras, para que o agente responda pelo crime do art. 37 da Lei de Drogas, sua colaboração deve ser obrigatoriamente eventual. Ou seja, apesar de não estar associado de maneira estável ou permanente a determinado grupo, organização ou associação, o agente colabora eventualmente com tais indivíduos, geralmente, com o objetivo de receber determinada remuneração pelos serviços por ele ocasionalmente prestados. Logo, se restar evidenciado que o agente estabeleceu um vínculo associativo estável e permanente com os destinatários das informações, passando a agir como um dos integrantes da associação criminosa, tendo como função precípua exatamente a prestação de informações, sua conduta deverá ser tipificada no art. 35 da Lei nº 11.343/2006" (in" LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL COMENTADA ". 2a Ed., Editora Juspodivm, pág. 764).

Em suma, descritos os fatos nos autos n. 0000630- 89.2018.8.26.0660, caberia ao juízo competente ponderar sobre a eventualidade da alegada colaboração para o tráfico e acolher a pretensão autoral nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal caso entendesse por atribuir definição jurídica diversa ao fato, reconhecendo a figura do informante, consagrada no art. 37 da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, superado o momento processual adequado para exame de todas as nuances da pretensão acusatória no feito anterior, entendo que, neste feito, estão acobertadas pelo manto da coisa julgada todas as imputações relativas a GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI, o que torna cogente o acolhimento da preliminar suscitada pela Defesa.

Presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições

imprescindíveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do mérito.

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pela portaria de fl. 02, boletins de ocorrência policial (fls. 04/05, 10/11 e 12/13), autos de exibição e apreensão (fls. 06/08 e 14), laudo de exame químico toxicológico (fls. 19/21), laudo pericial de objeto (fls. 42/45), mídia contendo imagens do local dos fatos (fl. 46) e respectivo laudo (fls. 141/148), transcrição das gravações de conversas entre HTs (fls. 109/110) e respectivo laudo pericial (fls. 131/140), bem como pela prova oral coligida.

O acusado LEONARDO MANINI, perante a autoridade policial (fl. 87), afirmou: "Eu era usuário de drogas, mais precisamente cocaína e maconha. No dia e hora dos fatos, eu havia acabado de fazer uso de cocaína, estando sobre a 'ponte do clube', perto da Avenida João dos Santos Filho, nesta cidade. Eu não tinha mais nenhum pino de cocaína comigo e, em dado momento, quando vi que uma viatura da Polícia Militar se aproximava, eu fiquei com medo e então resolvi correr. Foi o que eu fiz, ou seja, eu corri e não fui alcançado pelos policiais militares. Não dispensei nenhum 'pino' de cocaína pois eu não tinha mais nenhum, além daquele que usei momentos antes, nem mesmo maconha. Nunca usei nenhum aparelho de comunicação do tipo HT. Conheço o 'Bielzinho', mas nunca tive relacionamento de amizade com ele, apenas o cumprimentava quando o via na rua. Não sei se 'Bielzinho' traficava drogas na cidade. Nunca fui processado. Estou apenas arrependido de ter fugido da polícia, pois, na verdade, não tinha nada de errado, apenas que eu estava no efeito do uso de drogas, fiquei com medo e, então, corri".

Em juízo, LEONARDO MANINI reiterou que é apenas usuário de drogas e disse que, quando foi abordado, não tentou fugir e que nada com ele foi encontrado, situação que ensejou sua imediata liberação pelo militar WILLIANS JOAO ALVES PRIMO. Contou que, ao chegar em casa, ficou sabendo que foi procurado pelos policiais e que, ao ser encaminhado à Delegacia, permaneceu em silêncio e não assinou qualquer documento.

O acusado HIGOR HENRIQUE DE SOUZA, em solo policial (fl. 92), respondeu: "Eu sou usuário de maconha e não tenho nenhum tipo de envolvimento com tráfico de drogas. Conheço o 'Bielzinho', mas não sei se ele trafica drogas, embora haja um comentário de rua dando conta disso, mas não sei se é verdade. Eu tinha um aparelho HT, pois fazia ciclismo na modalidade trilha com alguns outros rapazes da cidade e o HT nós usávamos para nos comunicar e não nos perdermos nos locais onde íamos fazer a trilha. No dia e hora dos fatos, eu havia ido até a matinha na beira da Av. João dos Santos Filho, nesta cidade, onde havia feito uso de maconha e, logo após, quando já estava indo embora com minha bicicleta, fui abordado pelos policiais militares, os quais apreenderam meu HT que eu portava no momento dos fatos. Nesse HT era muito comum ouvir conversas de pessoas em outras sintonias e, no momento dos fatos, havia várias pessoas conversando e uma das vozes parecia ser do 'Bielzinho', mas não deu para ouvir direito o que ele estava conversando. Eu não tinha nenhum tipo de contato com 'Biel' pelo HT".

Sob o crivo do contraditório, o réu explicou que o rádio que portava era utilizado para comunicação durante trilhas de ciclismo e ressaltou que não estava conversando com GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI, pois estava apenas passando pelo local. Contou, ainda, que houve uma interferência no aparelho, o que fez com que o corréu entrasse na linha e fosse possível ouvir sua voz.

O acusado GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI, perante a autoridade policial (fl. 155), respondeu: "Sobre os fatos ora investigados, eu não sei de nada e não tenho nenhuma participação. Não me recordo de quem seja Leonardo Manini e, com relação, a Higor, eu o conheço. Fiquei sabendo que policiais apreenderam um aparelho HT com ele, mas eu nunca conversei com Higor por HT. Não é a minha voz a que consta das gravações do HT. Nada sei sobre tráfico de drogas no local das abordagens".

Em juízo, o acusado consignou que nunca tentou fugir de abordagens policiais e acrescentou que as questões ora em julgamento foram analisadas em processo que tramitou em 2018, que resultou em sua condenação.

A testemunha RONALDO ADRIANO LOPES, policial militar, ouvido na fase inquisitiva (fl. 15), narrou: "Recebemos informações de que estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas na área verde da Prefeitura, às margens do córrego Viradouro, próximo ao

Clube de Campo, na Avenida João dos Santos Filho, bairro Jardim Maria Luiza I e II, inclusive com filas de carros, à noite, para adquirir o entorpecente, sendo que, o chefe do tráfico seria um indivíduo conhecido pelo vulgo de 'Biel', conhecido nos meios policiais desta cidade por envolvimento no tráfico de drogas. 'Biel' teria montado um complexo sistema de venda de entorpecente, inclusive, com monitoramento de 'olheiros' com uso de rádios comunicadores. Fizemos algumas incursões no local indicado na denúncia anônima, e notamos que, ousadamente, teriam montado dois pontos de venda de entorpecente dentro da mata, com cadeiras, mesas e outros acessórios, instalando lonas na cerca para dificultar a nossa visão. Um dos pontos de venda de drogas, da mesma organização, fica defronte ao Centro de Fisioterapia da Prefeitura de Viradouro, já outro a alguns metros, nos fundos do Clube de Campo, perto de uma ponte. Notei que os traficantes e seus assecclas ficam percorrendo, pela mata, de um ponto para o outro, a droga fica enterrada em vários locais, de difícil localização e eles ficam apenas com pequenas quantidades para não serem presos por tráfico de drogas. Sempre que patrulho o local, os suspeitos, ao nos avistarem, empreendem fuga pulando no córrego e atravessando para o outro lado da margem. No dia 19/09/2017, na companhia do policial militar Willians, em patrulhamento, eis que nos deparamos com um indivíduo, no local dos fundos do Clube de Campo, e, ao notar nossa aproximação, evadiu-se, após verbalizarmos para que ele parasse, tendo jogado algo no solo e, em seguida, saiu correndo pelo meio da mata. Reconheci, prontamente, o indivíduo corno sendo Leonardo Manini, pois já o havia abordado em datas anteriores, no mesmo local. Não conseguimos detê-lo, porém, no local em que ele havia dispensado algo, encontramos quatro invólucros plásticos com maconha e cinco pinos de cocaína. Ato contínuo, fomos até a residência de Leonardo Manini, no entanto, não o encontramos. Em seguida, viemos até esta Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Mesmo após essa apreensão, no local acima indicado, o tráfico continuou intenso. Na data de ontem, em companhia do policial militar Valdecir, eis que nos deparamos com o indivíduo de vulgo 'Biel', denominado 'Patrão do Tráfico' no local, no fundo do Clube de Campo, no final da Avenida João dos Santos, em companhia do investigado posteriormente identificado nesta Delegacia como sendo a pessoa de Higor Henrique de Souza, e, quando eles perceberam nossa aproximação, cada um deles com um HT (Rádio de Comunicação) nas mãos, tentaram empreender fuga a pé, sendo que somente o Higor foi detido e Biel se evadiu. Com Higor, apreendemos um rádio HT, em funcionamento, ligado, e pudemos escutar que os traficantes se comunicavam entre si a respeito da nossa abordagem e detenção de Higor. Biel, pude escutar pelo rádio, pois conheço sua voz, dizendo diretamente a mim que, se eu não os deixasse 'trabalhar', iria ser 'lamentável', não iria ficar 'assim' e dariam tiro de 'fura'. Tudo foi gravado por celular pelo policial militar Valdecir, para que posteriormente pudesse ser usado como prova. Eles falam até mesmo em dar tiros de 'rajada' em nós, e que, hoje eles correm, mas amanhã irão resistir atirando em nós, trocando tiro de ponto".

Compromissado, RONALDO ADRIANO LOPES confirmou que realizou a abordagem de LEONARDO MANINI, que conseguiu se evadir, mas dispensou certa quantidade de entorpecentes durante a fuga, e disse que o local da ocorrência é conhecido ponto de venda de drogas. Ademais, expôs que já abordou o réu em contexto de consumo de substâncias proscritas em outras oportunidades. Quanto aos corréus, explicou que, realizada abordagem policial, GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI empreendeu fuga, mas HIGOR HENRIQUE DE SOUZA permaneceu no local com um radio transmissor e que, se utilizando do equipamento, GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI ameaçou a guarnição.

A testemunha WILLIANS JOAO ALVES PRIMO, policial militar, ouvido na fase investigativa (fl. 17), relatou: "Recebemos informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na área verde da Prefeitura, às margens do córrego Viradouro, inclusive com congestionamento de carros, à noite, para adquirir a droga, sendo que o chefe do tráfico seria um indivíduo conhecido pelo vulgo de 'Biel', conhecido nos meios policiais desta cidade por envolvimento no tráfico de drogas. 'Biel' teria arranjado um complexo sistema de venda de entorpecente, inclusive, com monitoramento de 'olheiros' com uso de rádios tipo HT. Fizemos algumas incursões no local indicado na denúncia anônima, e notamos que, atrevidamente, teriam montado

dois pontos de venda de entorpecente dentro da mata, com cadeiras, mesas e outros acessórios, instalando lonas na cerca para dificultar a nossa visão. Um dos pontos de venda de drogas, da mesma organização, fica defronte ao Centro de Fisioterapia da Prefeitura de Viradouro, já outro a alguns metros, nos fundos do Clube de Campo, perto de uma ponte. Notei que os traficantes e seus pares ficam percorrendo, pela mata, de um ponto para o outro, a droga fica enterrada em vários locais, de difícil localização e eles ficam apenas com pequenas quantidades para não serem presos por tráfico de drogas. Sempre que patrulho o local, os suspeitos ao nos avistarem, empreendem fuga pulando no córrego e atravessando para o outro lado da margem. No dia 19/09/2017, na companhia do policial militar Adriano, em patrulhamento, eis que nos deparamos com um indivíduo, no local dos fundos do Clube de Campo, e, ao notar nossa aproximação, evadiu-se, após verbalizarmos para que ele parasse, tendo jogado algo no solo e, em seguida, saiu correndo pelo meio da mata. Reconheci, prontamente, o indivíduo como sendo Leonardo Manini, pois já o havia abordado em datas anteriores, no mesmo local. Não conseguimos detê-lo, porém, no local em que ele havia dispensado algo, encontramos quatro invólucros plásticos com maconha e cinco pinos de cocaína. Ato contínuo, fomos até a residência de Leonardo Manini, no entanto, não o encontramos.

Sob o crivo do contraditório, contou ter realizado a abordagem de LEONARDO MANINI, que resultou na apreensão de entorpecentes que foram por ele dispensados ao se evadir da atuação policial. Relatou, contudo, não ter participado da apreensão do HT e da busca na casa de GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI.

A testemunha VALDECIR PINTO RIBEIRO, policial militar, ouvido na fase investigativa (fl. 34), narrou: "No dia dos fatos, eu estava trabalhando na companhia do policial militar Adriano, quando, em patrulhamento, eu pedi para Adriano me mostrar as regiões onde haveria intenso tráfico de drogas, então fomos até uma área verde existente na extensão da avenida João dos Santos Filho e, em dado momento, no referido local, de frente, deparamo-nos com a pessoa que Adriano disse ter o apelido de 'Biel', caminhando, com um HT na mão, ao lado de Higor Henrique de Souza, o qual, também tinha na mão um rádio HT, quando eles nos viram, tentaram empreender fuga, o Higor foi detido, porém o 'Biel' conseguiu evadir-se. Começamos a copiar o rádio que estava em poder de Higor, o policial Adriano, para fazer prova do que estava sendo dito no HT de Higor, pediu para que eu comesse a gravar com o meu celular, assim procedi. O policial militar Adriano me disse que um dos interlocutores do HT era o 'Biel', pois reconheceu a voz dele. 'Biel' e os outros interlocutores reclamavam da nossa presença ali, pois nós estávamos prejudicando o 'trabalho' deles, ou seja, o tráfico de drogas, fazendo ameaças, dizendo que seria lamentável para nós e que tiro de 'ponto' e trocariam tiro com a 'Polícia' dentre outras ameaças. Higor, indagado, disse-nos que teria comprado o 'HT', tendo em vista que estava andando com outro amigo, para que se comunicassem de bicicleta, negando qualquer envolvimento no tráfico de drogas. Eu cheguei a dizer que os caras estavam comentando sobre ele na rede, ou seja, dizendo que 'ele' havia sido pego, mas o Higor, mesmo assim, disse-nos que não tinha nada a ver. Notei que as conversaram se deram na canaleta 07 do rádio, mas o Higor disse que usava a canaleta 04 para conversar com seu amigo ciclista".

Em juízo, confirmou ter participado apenas da ação que resultou na apreensão do radio comunicador que estava em poder de HIGOR HENRIQUE DE SOUZA.

A testemunha EMERSON DA SILVA ABADE, Delegado de Polícia, ouvido em juízo, declarou que LEONARDO MANINI foi abordado por militares, que localizaram entorpecentes dispensados na mata. Relatou, ainda, que HIGOR HENRIQUE DE SOUZA e GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI foram encontrados por policiais conversando por rádios transmissores e que houve monitoramento das ações de GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI por aproximadamente 1 ano, pois o denunciado traficava em casa.

Após exame do conjunto probatório, entendo que a pretensão ministerial merece prosperar somente em relação a LEONARDO MANINI.

Em juízo, os militares RONALDO ADRIANO LOPES e WILLIANS JOAO ALVES PRIMO, descreveram com detalhes a abordagem realizada, a fuga do réu e as drogas apreendidas (fls. 6/8), sendo tudo corroborado pelo interrogatório do acusado, que, apesar de negar ser o proprietário dos entorpecentes, admitiu que foi abordado

pelos policiais no local descrito na denúncia.

Os laudos de fls. 19/21 e fls., 71/73 constataram que as substâncias localizadas em poder do réu seriam METIL BENZOIL ECGONINA (cocaína) e TETRAHIDROCANNABINOL - THC (maconha), entorpecentes proscritos pela Portaria SVS/MS 344/98.

O art. 33 da Lei de Drogas apresenta diversos núcleos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.

Na espécie, o conjunto probatório é incontroverso a demonstrar que trazia consigo 4,95 gramas de cocaína, acondicionados em 04 microtubos plásticos e 04 segmentos plásticos transparentes contendo 18,73 gramas de maconha, tudo com a finalidade de mercancia e sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Malgrado as alegações finais de fls. 367/396 por diversas vezes tragam "Helena" como a ré da ação penal, registro que as teses defensivas sustentadas ao longo do processo por LEONARDO MANINI não prosperam.

Observo que, não raro, denunciados sustentam serem usuários de drogas como se tal condição fosse uma automática excludente da configuração da traficância. Ora, diversos são os casos apreciados pelo Judiciário pátrio em que o agente passa vender entorpecentes justamente para sustentar o próprio vício. Assim, a despeito da possibilidade de valoração dessas circunstâncias na dosimetria, tal argumentação não tem envergadura, por si só, para enjeitar os seguros elementos acusatórios.

Em acréscimo, cumpre sempre ressaltar que a circunstância de ser policial a testemunha "não afeta positiva ou negativamente o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados" (TJSP; Apelação Criminal 0003165-95.2012.8.26.0370; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Azul Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 30/01/2014; Data de Registro: 04/02/2014).

No mesmo sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Condenação acertada. Permitido agravamento da pena em razão de maus antecedentes. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500667-03.2020.8.26.0618; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/11/2021; Data de Registro: 02/11/2021)

Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de cocaína e maconha - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras - Negativa isolada - Condenação mantida - Reincidência que não é específica - Regime mantido - Recurso provido em parte para adequação da pena. (TJSP; Apelação Criminal 1500229-37.2020.8.26.0210; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaíra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Assim, entendo que a versão apresenta pelos militares sobre a abordagem e a fuga do acusado se afigura sobremaneira verossímil, sobretudo a considerar que os entorpecentes foram devidamente apreendidos e que o local da ação policial é conhecido ponto de tráfico de drogas.

Quanto à incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, entendo atendidos aos requisitos legais em relação a LEONARDO MANINI. O denunciado é tecnicamente primário, não ostenta antecedentes, não integra organização criminosa, e não se dedica a atividades criminosas.

Consigno que deve militar em favor do réu a presunção de que atende aos requisitos legais, cabendo ao órgão acusatório demonstrar o contrário, o que não ocorreu na espécie.

Sobre o tema, transcrevo parte do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes relator

para o acórdão no HC 154694 AgR/SP, julgado pela 2ª Turma do c. Supremo Tribunal Federal em 4/2/2020:

A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

E também: "(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).

Como se sabe, o benefício ora examinado se destina ao pequeno traficante (traficante "de primeira viagem") e tenho que é exatamente essa a figura descrita nestes autos: indivíduo primário, sem registro negativos e possuidor de pequena quantidade de entorpecentes que pretendia comercializar. Em suma, tenho que as circunstâncias não delineiam um robusto traficante.

Ressalto que não milita em favor do réu qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas atitudes e não empreendeu esforços para agir conforme o direito.

Quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, que, como já esclarecido na análise das preliminares, deve ser examinado apenas em relação a LEONARDO MANINI e HIGOR HENRIQUE DE SOUZA, verifica-se que, diante da fragilidade das provas produzidas, não há elementos concretos para a condenação dos acusados. De pronto, registro que a relação que o Parquet estabelece entre os dois acusados tem por fundamento apenas a localização da abordagem de ambos, na mesma região, pois não há nenhuma outra informação segura nos autos a indicar que os denunciados mantenham algum tipo de relação.

A associação para o tráfico somente é punida na modalidade dolosa, ou seja, na deliberada intenção do agente de integrar a associação, assumindo tarefa específica, vinculada aos demais integrantes.

Nesse sentido, não basta "a existência de simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes. É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável". (MARCÃO, Renato. Tóxicos. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 252).

A ligação com a associação deve ser comprovada por provas objetivas que permitam identificar a missão do acusado dentro do grupo, além de prova específica a respeito da reunião estável e permanente dos agentes.

É a jurisprudência da e. Corte Bandeirante:

Associação para o tráfico de entorpecentes. Condenação em primeiro grau de 6 anos e 9 meses de reclusão. Preliminares. Suposta ilegalidade das provas, diante de eventual tortura. Postulação prejudicada, diante do teor do art. 282, §2º do CPC c.c. art. 3º CPP. Recurso para absolver. Possibilidade. Estabilidade e permanência que não ficaram comprovados. Orientação pacífica do e. STJ. Decisão que deve se estender ao corréu que não recorreu. Entendimento do art. 580 do CPP. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500129-05.2019.8.26.0247; Relator (a): Costabile e Solimene; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021).

Revisão criminal. Tráfico, associação e posse ilegal de munição. Insurgência exclusiva quanto à condenação pela associação. Alegada atipicidade. Ocorrência. Necessária distinção entre concurso de agentes e associação. Enquanto o primeiro se mostra ocasional e temporário, o segundo exige estabilidade e permanência. Fatos apurados que não demonstram o vínculo associativo duradouro. Embora reste bem



delineada uma transação comercial ilícita entre os envolvidos, tal circunstância não basta para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. Penas do tráfico e da posse ilegal de munição bem dosadas. Regime fechado mantido. Revisão julgada parcialmente procedente. (TJSP; Revisão Criminal 2245924-89.2018.8.26.0000; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Nova Odessa - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)

No caso em tela, a acusação não trouxe elementos que demonstrassem qualquer relação entre LEONARDO MANINI e HIGOR HENRIQUE DE SOUZA. Com efeito, não há provas sobre os moldes mínimos da associação, elementos imprescindíveis para a comprovação em juízo da prática da infração.

Desse modo, resta dúvida que favorece os acusados e, como se sabe, o Direito Penal exige a convicção plena, de maneira que a dúvida, menor que seja, milita em favor dos réus.

Por derradeiro, o Ministério Público imputa a HIGOR HENRIQUE DE SOUZA a prática do delito previsto no art. 37 da Lei de Drogas, que pune a conduta de colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei n. 11.343/2006, com pena de 2 a 6 anos de reclusão e pagamento de 300 a 700 dias-multa.

Cabe consignar, primeiramente, que “o art. 37 a Lei Federal nº 11.343/06, exceção à teoria monista prevista no art. 29 do Código Penal, aplica-se apenas ao “extraneus”, ou seja, àquele que, não integrando o grupo, auxilia-o como terceiro informante” (TJSP; Apelação Criminal 3000897-14.2013.8.26.0586; Relator (a): Augusto de Siqueira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Roque - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/08/2015; Data de Registro: 13/08/2015).

Em síntese, sem a existência do tipo penal, o agente que apenas colaborasse como informante de grupo, organização ou associação poderia ser enquadrado como partícipe do tráfico de drogas ou de maquinário.

Ocorre que, ainda que o art. 37 da Lei de Drogas seja uma exceção pluralística à teoria monista, àquele que auxilia no crime de outrem deve ser aplicada a teoria da acessoriedade limitada, ou seja, sua responsabilização depende da comprovação de que terceiros por ele amparados tenham praticado fato típico e ilícito.

Na espécie, se mostrou absolutamente inverossímil e fantasiosa a versão apresentada por HIGOR HENRIQUE DE SOUZA que, em autodefesa, afirmou ser ciclista para justificar o porte um rádio transmissor em local conhecido pelo contínuo tráfico de drogas.

Contudo, a acusação não foi capaz de se desincumbir de seu ônus probatório, trazendo ao presente feito elementos mínimos em relação à existência de grupo, organização ou associação que foi auxiliado pelo réu.

Assim, ainda que se reconheça que o acusado se comunicava com GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI no momento da abordagem policial ocorrida em 26 de setembro de 2017, nada há nos autos a demonstrar que o denunciado auxiliasse um grupo (concurso eventual de pessoas), organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.694/2012) ou associação (art. 35 da Lei nº 11/343/2006).

Não se olvide a possibilidade de, diante da ausência de elementares do art. 37 da Lei n. 11.343/2006, reconhecer que HIGOR HENRIQUE DE SOUZA seria partícipe em eventual tráfico de entorpecentes realizado por GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI. Entretanto, tal conclusão somente seria possível se comprovada a mercancia de substâncias proscritas no contexto fático da abordagem policial, o que não ocorreu.

Portanto, o reconhecimento da atipicidade em relação ao delito imputado é medida que se impõe.

Cogente o acolhimento parcial da pretensão acusatória, passo à individualização da pena de LEONARDO MANINI, nos termos dos art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 68 do Código Penal.

Em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assinalo que, quanto à culpabilidade, o réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo; quanto

aos antecedentes, o réu é tecnicamente primário e não ostenta antecedentes (fls. 180/183); os elementos coletados a respeito de sua conduta social e personalidade não se afiguram suficientes para apreciação aprofundada de tais circunstâncias; o motivo da comercialização de entorpecentes é o lucro fácil, punido naturalmente pelo tipo penal; as circunstâncias e as consequências foram as normais para esta espécie; por se tratar de crime contra a saúde pública, nada a considerar acerca do comportamento da vítima.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, e diante do comando do art. 68 do Código Penal, não vislumbro circunstâncias agravantes e reconheço a existência da atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a reprimenda até mínimo legal, em respeito ao verbete sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, considerando que o denunciado é tecnicamente primário, não ostenta antecedentes, não integra organização criminosa, e não se dedica a atividades criminosas, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, o que resulta em pena de 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa.

Ante a primariedade do réu e por serem as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicial aberto, para o início do cumprimento da pena de detenção, consoante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Ademais, por ser o réu primário e as circunstâncias judiciais favoráveis, a ele é cabível a substituição de pena prevista no art. 44, incisos e parágrafos, do Código Penal. Deixo de conceder o sursis da pena, em vista da substituição ora reconhecida.

Diante do exposto, ACOELHO A PRELIMINAR de coisa julgada em relação aos crimes imputados a GABRIEL FERNANDO SENHORINI SALUCESTTI (artigo 35, caput e artigo 37, caput, ambos da Lei 11.343/2006) e extingo o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 110, do Código de Processo Penal c/c art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (art. 3º do Código de Processo Penal).

No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para: CONDENAR o réu LEONARDO MANINI, qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, no regime inicial aberto. À luz do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, nos moldes e condições a serem estabelecidos na fase de execução, por considerar a medida suficiente para a reprovação e repreensão do delito;

ABSOLVER o réu LEONARDO MANINI, qualificado nos autos, em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

ABSOLVER o acusado HIGOR HENRIQUE DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, em relação aos crimes previstos no artigo 35, caput e artigo 37, caput, ambos da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, incisos VII e III, do Código de Processo Penal, respectivamente.

Considerando que o sentenciado respondeu ao processo em liberdade, e não se verificando a presença dos requisitos que autorizam a decretação de custódia preventiva, permito-lhe apelar em liberdade, se por outro motivo não se encontrar preso.